

1501870-33.2021.8.26.0628

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: Willi Lucarelli

Comarca: Embu-Guaçu

Foro: Foro de Embu-Guaçu

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 16/03/2022

... havia situação de flagrante pelo crime de tráfico de drogas, figura penal permanente, a justificar, sobremaneira, o ingresso na residência.

A esse respeito, confira-se o seguinte julgado:

"TRÁFICO DE DROGAS - RECURSO MINISTERIAL: PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA PENA-BASE - ACATAMENTO - FRAÇÃO ESTABELECIDADA PELO JUÍZO DE PISO MERECE READEQUAÇÃO EM FACE DA EXPRESSIVA QUANTIDADE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Embu-Guaçu

Foro de Embu-Guaçu

Vara Única

Rua Boa Vista nº 10, Embu-Guaçu-SP - cep 06900-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501870-33.2021.8.26.0628 - lauda SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501870-33.2021.8.26.0628

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2262341/2021 - DEIC-6ª

DEL.P.I.F.C.L.DINHEIRO, 20474655 - DEIC-6ª DEL.P.I.F.C.L.DINHEIRO, 131/21/215 - DEIC-6ª DEL.P.I.F.C.L.DINHEIRO, 2262341 - DEIC-6ª DEL.P.I.F.C.L.DINHEIRO

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

JORGE BEZERRA e outros

Réu Preso

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Willi Lucarelli

VISTOS.

JORGE BEZERRA, MARCEL HENRIQUE DA SILVA e OSMAR GOMES MEIRELES, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 33, caput, e 35 da Lei n.º 11.343/06.

Segundo a denúncia, no dia 24 de setembro de 2021, à noite, no endereço indicado na

inicial, os denunciados guardavam e mantinham em depósito, para consumo de terceiros, 100,9 quilogramas de cocaína na forma sólida, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Nos termos da inicial acusatória, os denunciados decidiram se associar para a prática do crime de tráfico de drogas, elegendo, para tanto, a chácara localizada na rodovia SP 215, km 42,5, n.º 51, Santa Rita, como sede da associação.

Processada, a denúncia fora recebida. Durante a instrução, foram ouvidas três testemunhas e, ao final, os réus foram interrogados.

O Ministério Público apresentou alegações finais, pugnando pela condenação dos réus somente pelo crime de tráfico de drogas, com a cominação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena.

A Defesa do réu MARCEL apresentou alegações finais escritas, apontando os seguintes argumentos para a absolvição do réu: nulidade do flagrante, pois os policiais ingressaram na residência de JORGE sem a sua autorização, eis que não havia situação de flagrante delito; ausência de provas de autoria; os policiais não souberam informar sequer o crime praticado pelo réu; o denunciado apenas acompanhada o réu OSMAR; ausência de prova da materialidade, já que não se sabe o local onde as drogas foram encontradas, a forma de armazenamento ou, ainda, quem seria o proprietário; não houve fotografias do local.

A Defesa dos réus JORGE e OSMAR apresentaram alegações finais escritas, apontando os seguintes argumentos para a absolvição dos denunciados: nulidade do flagrante, por ausência de autorização para ingresso na residência de JORGE; não houve fotografias ou vídeos da diligência policial; sem provas da existência de denúncia prévia; não houve busca quanto aos fugitivos; nada de ilícito foi encontrado na casa ou no corpo dos denunciados; as drogas foram encontradas longe da residência do denunciado; contradição entre as declarações dos policiais.

DECIDO.

Inicialmente, afasto a alegação de nulidade do flagrante, pois as declarações do réu JORGE de que não havia autorizado o ingresso acabaram por ficar isoladas diante das declarações dos policiais, destacando-se, ainda, que, na fase policial, o próprio réu assinou declaração de que “a ação se dera de forma tranquila e respeitosa, não havendo reclamação a ser feita, que autorizou a entrada e vistoria do imóvel” (fls. 09).

Em acréscimo, cabe salientar que os policiais mencionaram ter havido diligências prévias, consistentes em trabalho de campo, antes do ingresso no local, circunstância que, inclusive, constou expressamente do boletim de ocorrência (fls. 13/14), a legitimar a existência de fundadas razões para o ingresso no local.

A colocar de pá sobre a questão, afastando-se qualquer dúvida a respeito da ocorrência efetiva dessas diligências, em especial aquelas levantadas pela Defesa do réu MARCEL, não se pode desconsiderar que, ao final, 100 (cem) tijolos de cocaína foram encontrados em área integrante do imóvel.

De mais a mais, imprescindível consignar que havia situação de flagrante pelo crime de tráfico de drogas, figura penal permanente, a justificar, sobremaneira, o ingresso na residência.

A esse respeito, confira-se o seguinte julgado:

“TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO MINISTERIAL: PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA PENA-BASE – ACATAMENTO – FRAÇÃO ESTABELECIDADA PELO JUÍZO DE PISO MERECE READEQUAÇÃO EM FACE DA

EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS DIVERSAS – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO DEFENSIVO: PLEITO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – PROVA ILÍCITA – INOCORRÊNCIA – CRIME PERMANENTE – HIPÓTESE EM QUE O AGENTE PERMANECE EM ESTADO DE FLAGRANTE ENQUANTO NÃO CESSAR A PERMANÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA. PROCESSO-CRIME – RECURSO DEFENSIVO: PLEITO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE – BUSCA PESSOAL REALIZADA POR GUARDA CIVIL MUNICIPAL – TRÁFICO DE DROGAS – HIPÓTESE DE FLAGRANTE – SITUAÇÃO QUE NÃO SE CARACTERIZA COMO EXERCÍCIO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA OU INVESTIGATIVA – LEGITIMIDADE DE QUALQUER DO POVO REALIZAR A PRISÃO EM FLAGRANTE – ART. 301, DO CPP – PRELIMINAR REJEITADA. TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO DEFENSIVO: PLEITO DE APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º, DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006 – NÃO ACOLHIMENTO – ELEMENTOS PROBATÓRIOS A INDICAR LONGO PERÍODO DE CONTATO COM O MUNDO DAS DROGAS -- RECURSO DEFENSIVO IMPROVIDO. (TJSP; Apelação Criminal 1500386-08.2020.8.26.0631; Relator (a): Jayme Walmer de Freitas; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Socorro - 2ª Vara; Data do Julgamento: 15/03/2022; Data de Registro: 15/03/2022).”

Em suma, as provas foram obtidas de modo lícito, não havendo margem para o acolhimento da questão preliminar.

DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS;

No mérito, a ação penal deve ser julgada improcedente.

É que a caracterização do delito trazido pelo artigo 35 da Lei n.º 11.343/06 não demanda a simples convergência de vontades para a prática das infrações contidas nos artigos 33 e 34 da Lei de Drogas.

Na medida em que imprescindível faz-se a presença do denominado ânimo associativo, devidamente comprovado nos autos, porquanto se trata de figura integrante do tipo penal.

Compulsando os autos, especialmente a prova oral produzida, não se verifica a comprovação, a partir de elementos concretos, do vínculo de estabilidade, necessário para responsabilizar os acusados.

Ao contrário, observando as provas trazidas, não se denota, ainda que minimamente, circunstâncias suficientes, aptas a levar ao decreto condenatório.

Essencialmente porque, neste particular, a prova produzida em Juízo não trouxe a tranqüilidade necessária, e por isso, não serve de fundamento para eventual édito condenatório.

Sendo assim, existem apenas indícios, meras conjecturas, que não estão a demonstrar a imputação trazida na denúncia, culminando com a absolvição dos acusados pela ofensa ao artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/06.

DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS;

No mérito, cumpre reconhecer que, na análise da pretensão punitiva deduzida, a ação penal deve ser julgada parcialmente procedente, condenando-se o réu JORGE BEZERRA pelo crime de tráfico de drogas.

A materialidade do delito restou comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 12/15), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 16), pela fotografia acostada (fls. 17), pelo laudo toxicológico (fls. 254/256) e pela prova oral colhida.

Da mesma forma, diversamente do que afirmado pela combativa defesa, a prova vinda aos autos demonstrou, à saciedade, ao menos a responsabilidade criminal do mencionado réu, servindo, assim, de fundamento para o presente decreto

condenatório.

É certo que os réus negaram o ocorrido. O denunciado JORGE, na fase judicial, disse que reside no local em comodato, sendo certo que não há cerca no local, de modo que "encosta carro e caminhão" e que já tinha avisado à polícia, mas nada foi feito.

O denunciado afirmou, ainda, que estava em casa, ocasião em que recebeu uma ligação de OSMAR, que se ofereceu para comprar galinha e pato, tendo ido até a sua residência para comprar a galinha, tendo efetuado o pagamento da quantia de R\$ 200,00.

O réu disse, também, que o réu MARCEL estava do lado de fora e chegou a ir cumprimentá-lo, momento em que chegou a polícia atirando, de modo que escutou cerca de oito disparos.

O denunciado mencionou, inclusive, a polícia invadiu a sua casa e que, juntamente com MARCEL, foi levado para o lado de fora e, posteriormente, conduzido até DEIC, onde tomou conhecimento da acusação.

Sobre os cômodos existentes do lado de fora da casa, o réu disse que era uma "garagem de nove por nove, aberta, lá tem ferro de construção e bloco", sendo que, ao lado da garagem, havia um quartinho para cavalo e o cômodo onde as drogas foram localizadas ficam a cerca de sessenta metros e, por isso, nunca tinha visto o local, muito embora estivesse dentro da propriedade.

Por fim, o réu reafirmou que "o mato era frequentado por bastante pessoas" e que chegou a avisar à polícia por várias vezes.

Da mesma forma, o denunciado MARCEL, na fase judicial, disse que sempre teve convivência com o réu OSMAR e que, no início da semana, foi convidado por ele para ser padrinho de seu filho, ocasião em que combinou com o denunciado OSMAR de ir na sexta-feira na casa de um amigo dele para comprar galinhas, a fim de comemorar.

O denunciado afirmou que, após pegar o carro de sua irmã emprestado, passou na casa de OSMAR e se dirigiu até a residência de JORGE, local onde sequer entrou, sendo certo que, enquanto aguardava do lado de fora, os policiais chegaram efetuando disparos.

O réu disse, ainda, que foi colocado ao chão e, em seguida, a polícia saiu com os réus OSMAR e JORGE algemados, tendo afirmado que, posteriormente, foram todos conduzidos até o DEIC.

Sobre o local e motivo de não ter ingressado na casa, o denunciado afirmou que é tímido e estava com pressa, por isso, não ingressou na casa, de maneira que, por estar escuro, conseguia ver apenas a casa e que o "terreno grande não tem nada."

Por fim, o denunciado falou que ficou "do lado de fora do murinho" e que o murinho tinha um portãozinho, reafirmando que estava no local apenas e tão somente para comprar quatro galinhas, tendo efetuado, para tanto, o pagamento de R\$ 200,00.

Seguindo essa linha, o réu OSMAR, na fase judicial, afirmou que, após conversar com sua esposa, decidiu convidar MARCEL para ser padrinho de seu filho e, assim sendo, havia comentado que conhecia JORGE, que poderia fornecer as galinhas, ocasião em que combinou de sexta-feira ir até a sua casa.

O denunciado falou que, ao chegar na casa de JORGE, entrou no local e o réu MARCEL permaneceu do lado de fora, pois estava com pressa, momento em que ouviu tiros, deparando-se com os policiais na entrada da casa.

O réu disse, também, que tomou conhecimento da acusação por tráfico de drogas apenas e tão somente no DEIC.

A respeito do local, o denunciado esclareceu que do lado de fora da casa havia uma garagem, onde tem uma bomba de lavar carro e ferramentas de JORGE, dizendo, ademais, que ao chegar ao local é possível visualizar os cômodos, que "ficam colados na casa dele", principalmente quando "ele usa aquela luz da casa dele."

O denunciado informou que não sabe acerca do local onde as drogas foram encontradas, não tendo visto ninguém correndo, sendo certo que "JORGE reclamou de pessoas que jogam pedras no local."

Contudo, as alegações não encontram perfeito amparo na prova dos autos, que foi firme e segura em confirmar, sem sombras de dúvidas, ao menos, ter o réu JORGE BEZERRA, deliberadamente, guardado e mantido em depósito os 100 (cem) tijolos de cocaína.

Neste sentido, a testemunha de acusação WILLIAM FERREIRA, policial civil que participou da diligência, seja na fase policial, seja na fase judicial, não titubeou em ratificar os termos da acusação.

O policial disse que obteve a informação de que o local "seria uma chácara do PCC", tendo recebido informes de que estaria ocorrendo transporte de armas no dia dos fatos.

O policial afirmou que, após chegarem no local, duas pessoas correram para o mato, de modo que apenas o réu MARCEL permaneceu parado, ocasião em que foi revistado e nada de ilícito foi encontrado.

A testemunha disse, também, que, no interior da residência, havia mais duas pessoas, momento em que, após autorização do morador, passaram a realizar busca na casa, mas nada de ilícito foi encontrado.

O policial reafirmou que, ao redor do imóvel, havia vários cômodos, servindo de canil e depósito de material, bem como um cômodo mais isolado e mais escuro, sendo certo que, neste local, após retirar uma madeira que cobria o chão e um armário velho, identificou a existência de um buraco, contendo inúmeros tijolos de cocaína.

Sobre as informações a respeito do local, o policial falou que tomou conhecimento dos ilícitos no imóvel, a partir de investigação de campo, denúncias anônimas e informes do departamento de inteligência.

A respeito do imóvel, o policial falou que havia um portão, mas não existia muro e que MARCEL estava próximo da casa de JORGE, mas não estava tão próximo do quartinho, reafirmando que o quartinho onde foram apreendidas as drogas ficava na chácara.

No mesmo sentido, foram as declarações do policial civil GUSTAVO SOUZA, que, na fase judicial, disse que havia recebido informações de campo sobre o tráfico no local e, após autorização da equipe da Delegacia, foi até a residência.

O policial afirmou que, após chegar até o local, algumas pessoas correram e, em poder da pessoa que estava do lado de fora, nada de ilícito foi encontrado, sendo certo que, no interior da casa, após autorização do proprietário, nada foi localizado, no entanto, os entorpecentes foram encontrados em um quartinho, que fica no quintal do terreno.

A testemunha falou que o proprietário foi cientificado no local acerca da apreensão das drogas, confirmando que residia no local com sua família, tendo apresentado

poucas justificativas a respeito, inclusive, com referência às pessoas que haviam corrido.

Sobre as informações de campo, o policial deixou claro que “pessoas que tinham conhecimento” acabaram por passar informações sobre o local, não se tratando de nenhum informante.

A respeito do denunciado MARCEL, o policial disse que ele não tentou correr e que apenas o proprietário foi quem acompanhou os policiais para verificar as drogas localizadas dentro de um dos “quartinhos”, que era rústico para guardar ferramentas, sendo que as drogas estavam no interior de um buraco, escondido com tábuas.

O policial disse, por fim, que pessoas estavam correndo, no entanto, por falta de logística e por se tratar de local fechado, não houve perseguição, esclarecendo que o réu MARCEL estava no terreno que corresponde à chácara.

Na fase investigativa, os policiais civis trouxeram versão parecida (fls. 07/08).

Não há provas que tenham o condão de desconstituir a presunção de legitimidade do ato praticado pelos agentes públicos, de modo a indicar que a diligência policial foi perpetrada em função de interesses escusos.

Realmente, não se nega que, por vezes, haja desvios de finalidade na prática de atos administrativos, infelizmente, movidos por interesses que não se compatibilizam com as funções precípuas do Estado, mas não parece ser o caso dos autos.

É que não seria razoável que os policiais civis tivessem trazido consigo 100 (cem) tijolos de cocaína, devidamente embalados, como demonstram as fotografias de fls. 17, com o único propósito de forjar um ato de flagrante, exclusivamente, em desfavor de réu que, sequer, tinham qualquer rixa ou desentendimento.

Não havendo nenhuma prova concreta que esteja a apontar que a diligência foi forjada, na medida em que não foi produzida nenhuma prova concreta no sentido de, efetivamente, trazer contradições na versão dos policiais.

Muito pelo contrário, analisando as provas colhidas, em especial o interrogatório do próprio denunciado JORGE na fase judicial, denota-se que inexistem elementos que indiquem o cômodo onde foram localizados os entorpecentes não pertenciam ao imóvel do réu, a enfraquecer o argumento da Defesa de MARCEL de que não havia fotografias do local.

Neste ponto, inclusive, deve-se salientar que, muito embora os policiais tenham mencionado que indivíduos correram para o mato, após a chegada da viatura, pesa em desfavor do réu o fato de não ser crível e não haver provas em sentido contrário de que não tinha conhecimento sobre a utilização do cômodo para guardar entorpecentes.

Ainda mais, quando se considera que os cômodos poderiam ser visualizados pelo denunciado JORGE, sendo certo, a este respeito, que o próprio denunciado OSMAR, na fase judicial, disse, com todas as letras, que, logo após chegar ao imóvel, é possível visualizar os cômodos que “ficam colados na casa dele”, principalmente quando “ele usa aquela luz da casa dele.”

Ademais, pesa fortemente em desfavor do réu JORGE o fato de sequer ter trazido aos autos comprovação mínima de que teria avisado à polícia acerca da utilização indevida do local, conduta plenamente exigível.

Em suma, sob todos os ângulos analisados, diante de todas essas circunstâncias

descritas, os elementos de prova isolam a negativa do denunciado JORGE BEZERRA, de modo a demonstrar que, no mínimo, tinha conhecimento acerca da guarda e depósito dos entorpecentes em seu imóvel, conduta mais do que suficiente para o enquadramento no tipo penal do tráfico de drogas.

Afinal de contas, para a configuração dos verbos penais imputados, não se exige qualquer ato de tráfico, bastando que o agente tenha em depósito ou guarde a substância entorpecente, não se exigindo a denominada traditio para consumação do delito.

Portanto, a condenação do réu JORGE BEZERRA pelo crime de tráfico de drogas é medida que se impõe.

Com referência aos denunciados OSMAR e MARCEL, a prova colhida não trouxe a necessária tranquilidade para a edição de decreto condenatório.

Realmente, a versão dos acusados traz consigo pontos duvidosos, em especial relativamente ao fato de terem ou não se comunicado antes com o réu JORGE BEZERRA, cabendo considerar, neste ponto, que seria prova perfeitamente exigível por parte da Defesa, a fim de esclarecer a questão.

No entanto, muito embora não se vislumbre a ocorrência de qualquer nulidade no flagrante realizado, em razão dos motivos já expostos, o fato é que a diligência relacionada aos réus OSMAR e MARCEL acabou por ser realizada em momento inoportuno.

Obviamente, revelam-se razoáveis as justificativas trazidas pelos policiais sobre as dificuldades logísticas, em função do local propriamente dito, e do fato de haver notícias de que o imóvel era utilizado por organização criminosa.

No entanto, diante da existência de diligências prévias, haveria margem segura para que os policiais tivessem se valido da prerrogativa do flagrante prorrogado, ou retardado, constante do artigo 53, inciso II, da Lei n.º 11.343/06, a fim de melhor delinear o contexto probatório e, quiçá, a conduta denunciados OSMAR e MARCEL.

A questão seria mais necessária, quando se leva em consideração que os denunciados não eram efetivamente os proprietários do imóvel, de modo que, assim sendo, imprescindível seria a existência de provas de que os réus, às claras, estavam a guardar e manter em depósito os entorpecentes, prova inexistente nos autos.

Relativamente ao acusado MARCEL, a insuficiência probatória revela-se mais cristalina, na medida em que foi localizado no interior do imóvel, mas na parte de fora da casa existente no local.

Em acréscimo, não se pode desconsiderar que a testemunha MILENA, irmã de MARCEL, na fase judicial, disse que, por volta das sete horas da noite, MARCEL pediu o carro emprestado para ir comprar galinhas juntamente com OSMAR, o que não deixa de demonstrar que poderia estar no local para outra finalidade.

Em resumo, não havendo provas de que, às claras, os denunciados OSMAR e MARCEL estavam relacionados com a guarda e depósito das drogas, a absolvição de ambos os réus é medida que se impõe.

Assim sendo, passo a dosar a pena:

Sopesadas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, a pena-base deve ser fixada em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, 1/6 acima do mínimo legal.

Justifica-se a exasperação, em função das circunstâncias do crime, porquanto

existem notícias nos autos, a partir de declarações dos policiais, de que o local estava a servir para a guarda e depósito de drogas para organização criminosa.

A corroborar esse entendimento, não se pode desconsiderar que os agentes públicos mencionaram que indivíduos fugiram do local dos fatos, embrenhando-se no mato, abrindo-se margem para a conclusão de que não se tratava de ação isolada do réu JORGE.

Na segunda fase de aplicação da pena, majoro a reprimenda em 1/6, em razão da reincidência do réu, que foi condenado, com trânsito em julgado, nos autos do Processo n.º 1429-05/2016 (fls. 88), totalizando 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Na terceira fase de aplicação da pena, deixo de aplicar a causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06, eis que a aplicação do dispositivo demanda o preenchimento cumulativo de seus requisitos, desde que associados às circunstâncias do artigo 42 da Lei de Drogas.

No presente caso, as peculiaridades do caso, especialmente a grande quantidade de drogas apreendidas no local, que girou em torno de 100 (cem) tijolos de cocaína (fls. 16/17), mais a sua forma de armazenamento, porquanto as drogas estavam escondidas em cômodo diverso da casa, embaixo de um buraco, escondido por madeiras e um armário, fazem concluir que se dedica a atividades criminosas, não se tratando de criminoso não habitual.

Em acréscimo, deve-se destacar que o réu é reincidente (fls. 88), elemento a mais a indicar que não se tratou de ato isolado em sua vida.

Sobre os maus antecedentes criminais como motivação idônea para a negativa à aplicação da causa de diminuição, confira-se o seguinte julgado:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITOS DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE E DE ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. MATÉRIAS ANTERIORMENTE APRECIADAS PELA CORTE SUPERIOR EM HABEAS CORPUS CONEXO. REITERAÇÃO COM IDÊNTICOS FUNDAMENTOS E PEDIDO NO RECURSO ESPECIAL. PREJUDICIALIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4º DA LEI N. 11.343/2006. MAUS ANTECEDENTES. REQUISITOS LEGAIS CUMULATIVOS. NÃO PREENCHIMENTO. NATUREZA E QUANTIDADE DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Inviável a apreciação de matéria constitucional por esta Corte Superior, ainda que para fins de prequestionamento, porquanto, por expressa disposição da própria Constituição Federal (art. 102, inciso III), se trata de competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. Precedentes.

2. É cediço na jurisprudência desta Corte Superior que a análise anterior das matérias objeto do recurso especial nos autos de habeas corpus impetrado com idênticos fundamentos e pedidos implica perda de interesse recursal e prejudicialidade da pretensão recursal. Precedentes.

3. Na espécie, os pleitos atinentes à desproporcionalidade do quantum incrementado à pena-base e ao abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena foram anteriormente apreciados por este Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Habeas Corpus n. 672.615/SP, impetrado pela mesma parte, contra o mesmo acórdão, sob os mesmos fundamentos e com os mesmos pedidos. Assim, inafastável o reconhecimento da prejudicialidade do recurso especial, nos pontos.

4. Para fazer jus à incidência da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 a 2/3, a depender das circunstâncias do caso concreto.



5. In casu, consoante asseverado pelas instâncias ordinárias, o recorrente ostenta múltiplas condenações anteriores, também por tráfico de drogas, configuradoras de maus antecedentes (e-STJ fls. 465 e 609) - o que, por si só, constitui fundamentação idônea para afastar a benesse pleiteada, ante o não preenchimento de um dos requisitos legais cumulativos previstos no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 -, além de ter sido preso em flagrante delito por transportar e guardar, para fins de tráfico, 163,480kg de cocaína (e-STJ fl. 602). Nesse contexto, inviável a aplicação da privilegiadora postulada.

6. Agravo regimental não provido. (grifo nosso).

(AgRg no REsp 1970177/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022)."

Em suma, sob todos os ângulos analisados, possível concluir que não faz jus à causa de diminuição.

Sendo assim, torno definitiva a pena em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e, nos termos do artigo 42 da Lei n.º 11.343/06, fixo em 500 (quinhentos) dias-multa, a razão de 1/30 do valor do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, corrigido monetariamente, a contar da mesma data.

O regime inicial de cumprimento de pena será o fechado, considerando as provas de que se dedicava a atividades criminosas, mais a sua reincidência, de modo que a imposição de regime menos rigoroso não surtirá qualquer efeito.

Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado, consoante aresto que passo a transcrever:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Não há como aplicar a minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 quando verificado que a Corte de origem - dentro do seu livre convencimento motivado - apontou elementos concretos dos autos que evidenciam a dedicação do acusado a atividades criminosas.

2. As peculiaridades do caso concreto (quantidade e natureza da droga, bem como a dedicação do acusado ao narcotráfico) justificam a imposição de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da reprimenda aplicada.

3. Ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada.

4. Agravo regimental não provido. (grifo nosso).

(AgRg no HC 566.498/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020)."

Não havendo qualquer influência o tempo de pena provisória cumprida, para fins de detração penal, porquanto ofensiva ao princípio do juiz natural e da individualização da pena.

O réu não poderá apelar em liberdade.

Não se nega que, em função da cautelaridade da prisão provisória, o pedido deve ser juridicamente possível, ou seja, não deve encontrar obstáculo em qualquer das vedações legais previstas na Lei n.º 12.403/11.

Contudo, no caso em exame, houve decreto de prisão preventiva, que esteve a considerar todas estas circunstâncias legais e fáticas, em decisão, até então, mantida pelo Egrégio Tribunal de Justiça (fls. 350/354).

E, neste meio tempo, nada houve que tivesse o condão de apontar a existência de fatos novos, inclusive jurídicos, senão aqueles que subsidiaram a r. decisão

lançada.

Muito pelo contrário, a comprovação do vínculo do réu JORGE com a grande quantidade de drogas encontradas, frise-se mais uma vez, cerca de 100 (cem) tijolos de cocaína, permite a conclusão de que se tratou de anormal violação ao bem jurídico tutelado pela norma penal, reafirmando-se ser a prisão necessária para fins de manter incólume a ordem pública.

A reforçar a violação à ordem pública, como motivo que autoriza a sua prisão cautelar, não se pode desconsiderar que os agentes públicos mencionaram que o local era utilizado por organização criminosa para a guarda de drogas, circunstância que não deixa de corresponder à prova dos autos, principalmente quando se considera a quantidade e forma de armazenamento.

A esse respeito, confira-se o seguinte julgado:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos arts. 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.

2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente.

3. As condições pessoais favoráveis do agente não impedem, por si sós, a manutenção da segregação cautelar devidamente fundamentada.

4. O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública.

5. O exame pelo Superior Tribunal de Justiça de matéria que não foi apreciada pelas instâncias ordinárias enseja indevida supressão de instância, com explícita violação da competência originária para o julgamento de habeas corpus (art. 105, I, c, da Constituição Federal).

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 710.852/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 11/03/2022).”

Em arremate, cabe salientar que o réu é reincidente em crime doloso, peculiaridade que autoriza a conclusão de que existe risco concreto de reiteração criminosa, caso seja colocado em liberdade, justificando-se a sua prisão, para fins de aplicação da lei penal.

Assim, sob todos os ângulos analisados, não há qualquer constrangimento ilegal que esteja sendo imposto à liberdade de locomoção do réu JORGE, sendo de rigor a manutenção da medida.

DO DISPOSITIVO.

Ante o exposto, CONDENO JORGE BEZERRA, qualificado nos autos, À PENA DE 06 (SEIS) ANOS, 09 (NOVE) MESES e 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO, a ser cumprida inicialmente em REGIME FECHADO, e 500 dias-multa, a razão de 1/30 do salário-mínimo na data dos fatos, corrigido monetariamente, a contar da mesma data, como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.

ABSOLVO JORGE BEZERRA, qualificado nos autos, da imputação relacionada ao crime previsto no artigo 35 da Lei n.º 11.343/06, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

ABSOLVO MARCEL HENRIQUE DA SILVA e OSMAR GOMES MEIRELES, qualificados nos autos, de todas as imputações trazidas, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Por conseguinte, expeça-se alvará de soltura clausulado, em favor dos réus MARCEL e OSMAR.

DECRETO a perda, em favor do Estado, de todos os bens apreendidos, nos termos do artigo 63 da Lei n.º 11.343/06.

Não havendo mais necessidade na preservação do entorpecente apreendido, oficie-se determinando a sua incineração, se for o caso.

Com o trânsito em julgado, lance-se o nome do condenado JORGE BEZERRA no rol dos culpados. Custas na forma da lei.

Registre-se e comunique-se, com as anotações de estilo.

Embu-Guacu, 16 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA